

1500481-69.2022.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... comercial para disseminação do tráfico.

No caso em tela, desse modo, se vislumbra a reunião estável e permanente, almejando a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Oportuno consignar que, idêntico ao tráfico de entorpecentes, a associação para o tráfico também possui natureza jurídica de crime equiparado ao hediondo e, por isso, deve ter a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500481-69.2022.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500481-69.2022.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Victor Gonçalves de Lima e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. LUAN BATISTA ALVARENGA e VICTOR GONÇALVES DE LIMA, respectivamente qualificados nos autos a fls. 06 e 31, foram denunciados e viram-se processados como incursos no artigo 33, caput c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 e Victor ainda como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03, porque em data incerta, abrangendo, porém, o dia 13 de junho de 2022, em horário e local incertos, nesta cidade e Comarca de Guaíra, juntamente com Paulo Ricardo Braga de Souza (que teve o processo desmembrado – fls. 208/210), teriam se associado para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, bem como no dia 13 de junho de 2022, por volta das 20h15min, na Rua 38 nº 565, Bairro Miguel Fabiano, nesta cidade e Comarca, conluiados e mediante unidade de desígnios, teriam trazido consigo, para fins de tráfico, treze porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 3,670 g, bem como teriam em depósito, para fins de tráfico, seis porções de maconha, com peso líquido aproximado de 805,950 g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regular. Ademais, ainda verte a denúncia que, nas mesmas condições de tempo e espaço, Victor possuiria munição de uso permitido, consistente em quatro cartuchos íntegros de calibre .38, em seu local de trabalho, sendo ele o responsável legal do estabelecimento.

É da inicial que “os denunciados se associaram para a prática do tráfico de drogas, realizando tal atividade no local dos fatos, estabelecimento comercial cujo responsável é VICTOR e que é ponto conhecido por tal espúria atividade. Policiais militares receberam a informação de que no local dos fatos estava sendo realizado o tráfico de drogas, razão pela qual foram ao ponto indicado. Ao chegarem ao estabelecimento comercial, cujo responsável é VICTOR, encontraram com PAULO RICARDO treze porções de 'cocaína' e a quantia de sessenta e cinco reais em cédulas diversas. No balcão do estabelecimento, os policiais encontraram quatro munições intactas de calibre .38 e a quantia de duzentos reais. Em um cômodo anexo ao estabelecimento, foram encontrados ainda um tijolo de 'maconha', duzentos eppendorfs vazios, cinco porções de 'maconha', uma balança digital e quarenta e quatro emblemas pequenos, com desenho de um jacaré. LUAN, durante a abordagem, confessou a traficância e disse que tudo lhe pertence, sendo com ele encontrados um aparelho celular e a quantia de duzentos reais”.

A denúncia, encartada em fls. 130/133, foi recebida em 24 de junho de 2022 (fls. 137/138). Os Acusados foram citados a fls. 181 e 240, apresentando defesas preliminares a fls. 189/190 e 193/199, rejeitadas a fls. 208/210. Durante a instrução foi colhida prova testemunhal e, ao final, os Réus foram interrogados (fls. 297).

Em memoriais o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, requerendo a condenação de Luan e Victor nos exatos termos da denúncia (cf. fls. 295/296).

A Defesa de Victor, a fls. 298/301, arguiu preliminar e no mérito sustentou a ausência de justa causa, de forma que requereu a improcedência da denúncia, absolvendo-se o Acusado e, subsidiariamente, fosse substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, permitindo recorrer em liberdade.

De igual modo, Luan pediu sua absolvição, ressaltando ausência de provas (fls. 302/309).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A preliminar arguida em memoriais defensivos do Corréu Victor não inova nos termos de sua pretensão inicial que já foi refutada pela decisão de fls. 208/210. No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está evidenciada no auto de prisão em flagrante de fls. 01/39, no boletim de ocorrência de fls. 40/44, no auto de exibição e apreensão de fls. 45/46, laudo de constatação de fls. 50/52, laudo pericial de exame em peça de fls. 159/160, auto de constatação definitivo em fls. 277/278, no laudo pericial de fls. 274/276, bem como pela prova oral colhida durante a persecução.

Por seu turno, a autoria é certa contra os Réus, que na fase inquisitorial optaram pelo silêncio (cf. fls. 04 e 29), ao passo que em Juízo Victor negou o teor da denúncia, declarando que na data dos fatos trabalhava no bar de seu genitor e havia cerca de quinze pessoas, quando policiais chegaram em três viaturas, revistaram todos e vasculharam o local, encontrando na gaveta a munição, que pertencia ao seu pai e, dali, os militares saíram e retornaram novamente pulando um muro, carregando uma sacola, dizendo que tinham encontrado droga em uma casa, no fundo do bar, mas não sabe quem reside ali, muito embora não tenha presenciado a apreensão. Ademais, disse que não conhecia os demais acusados e é perseguido pelo policial Deivid.

Luan, por sua vez, também negou a denúncia, declarando ser barbeiro e no dia dos fatos tinha ido até uma barbearia em frente ao bar para conversar com seu proprietário para tentar trabalhar com ele, mas como esse profissional estava com um cliente, foi até o bar tomar refrigerante e comer um salgado, quando, então, policiais chegaram ao local, abordaram todos, voltando com a droga ao pularem um muro, perguntando para as pessoas que ali se encontravam quem tinha passagem, prendendo quem assim respondia positivamente. Depois disso, dirigiram-se até sua casa, discutiram com seus familiares e levaram-no até a delegacia, onde, depois de ter sido agredido e ameaçado pela polícia, assumiu a propriedade da droga, por medo, muito embora não fosse sua. Por fim, disse que não conhecia os demais acusados, é perseguido pelo policial Deivid e o bar é longe de sua residência.

De início deve ser destacado que, como se sabe, o direito ao silêncio é cláusula constitucionalmente assegurada, mas não é crível se acreditar que aquele que tenha sido injustamente preso pela prática de um crime assemelhado ao hediondo tivesse a frieza de manter-se calado no inquisitorial para somente em Juízo informar a prisão equivocada, demonstrando que os Réus nada tinham a indicar em sua defesa no momento da prisão, cabendo salientar brilhante excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, quando se “assumiu comprometedor, ainda que legalmente tolerada, postura silente, quando é certo que aquele que se vê injustamente acusado, trata, logo, de anunciar a injustiça da acusação, se convidado a falar sobre ela” (TJSP, Ap. 990.09.059887-5, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 04.08.2009).

O policial militar Deivid, em Juízo, disse que tinha várias denúncias de que o bar era utilizado como ponto de venda de drogas, tendo ocorrido outras prisões em flagrante por tráfico, de forma que reuniu policiais e em três viaturas para lá se deslocaram, abordando, na porta do bar, Paulo e Victor, sendo que Luan estava em uma cadeira atrás do balcão. Com Paulo havia droga e dinheiro, localizando, com Victor, dinheiro em notas pequenas e, com Luan, dinheiro e celular. Em vistoria no estabelecimento encontraram na gaveta do balcão quatro munições calibre .38 e próximo à mesa de sinuca havia uma espécie de cozinha muito pequena, em anexo ao bar, encontrando uma sacola que continha o tijolo de maconha, porções do mesmo entorpecente, uma balança, eppendorfs vazios virgens e adesivos utilizados para distinguir uma biqueira da outra, sendo que os eppendorfs que estavam com Paulo tinham esse mesmo adesivo colado. De outro modo, o bar pertence ao pai de Victor e Luan admitiu a propriedade da droga. Declarou, ainda, que todos são conhecidos pelo tráfico de drogas, não aparentavam que estivessem sob efeito de entorpecentes, Paulo é sempre visto na esquina do bar, estabelecimento que é um ponto de apoio para traficantes que ficam nas imediações. Esclareceu, ademais, que o anexo em questão é no mesmo lugar físico do bar, mas não se trata de área de acesso público, somente mediante permissão do proprietário e que na parte de fora tinha dois casais de clientes, que foram abordados. Em linhas gerais, esse foi o teor do depoimento do militar Michel, que ainda esclareceu que os acusados são vistos no bar ou no

entorno.

Aldo, testemunha arrolada pela Defesa, disse que é vizinho de muro do bar há três anos, que na esquina ao lado tem um portão que não é fechado e no fundo do estabelecimento existe um imóvel abandonado onde entra qualquer pessoa. Ademais, Victor faz serviço comunitário e a tarde trabalha no bar.

Da análise do contexto fático-probatório, inegável que Luan e Victor praticaram os crimes descritos na exordial. O teor da prova colhida dá conta da participação de ambos os Acusados no tráfico de drogas, quando certo que estavam em atos que denotavam traficância, conforme depoimentos dos policiais acima mencionados, que nenhum envolvimento tinham com os Réus que justificariam prestar depoimento falso para prejudicar inocentes, observando-se que Victor se encontrava no bar de seu pai, onde alegou ali trabalhar e o entorpecente foi localizado naquele local, conhecido ponto de venda de drogas e apoio aos traficantes que orbitam nas redondezas, segundo seguro depoimento dos policiais, ao passo que Luan, que em Juízo quis fazer crer que estava no local por uma coincidência, foi localizado pelos policiais, quando ali chegaram, sentado em uma cadeira dentro do balcão, situação impossível de ocorrer se não tivesse vínculo claro com aquele local.

Some-se a isso que ambos os Réus são conhecidos dos meios policiais, não se encontravam sob efeitos de drogas e os álibis por eles declarados nem de longe foram comprovados, não podendo se perder de vista que tiveram a disposição ampla possibilidade de produzir provas, mas somente fora ouvida uma testemunha, que disse ser vizinho do bar e, pelo que se tem, sequer presenciou a abordagem dos policiais.

Não bastasse, a grande parte do entorpecente foi encontrada em um cômodo que não era de acesso aos frequentadores, sendo de acesso privilegiado a quem fosse autorizado e não é de se supor que em um ambiente como o retratado, com dois dos Acusados reincidentes específicos pelo tráfico, alguém se dispusesse a, sem autorização dos Acusados, ingressar ali e guardar o entorpecente e petrechos, incluindo adesivos distintivos de um ponto de venda de drogas específico, do mesmo tipo daquele encontrado com o terceiro que teve o processo desmembrado, com o que não se pode falar em ausência de justa causa.

Importante ainda ressaltar que Victor estava no local, onde ali desempenhava atividades e inegavelmente tinha controle da situação, em clara ascendência sobre quem ali estava, tanto que Luan, naquele momento, se dispôs a assumir a propriedade da droga, situação que se repete sempre que alguém em nível hierárquico inferior no tráfico é preso, visando resguardar aquele que possui posição de maior destaque e, com isso, até mesmo proteger sua integridade física, dada a possível retaliação no meio criminoso caso não o faça. Luan, por sua vez, admitiu que a droga era dele para os policiais, o que foi em Juízo confirmado, apesar de negar que isso fosse verdade, dizendo ter sido coagido pelos policiais para assumir a propriedade, inclusive na delegacia, onde teria sido agredido e, ainda, teria o delegado lhe dito que somente tomaria seu depoimento se fosse para confessar, situação extrema que, estranhamente, não teria surtido efeito, porque ele permaneceu em silêncio (cf. fls. 04). Ademais, é de se notar que em audiência de custódia ele nada falou a respeito de ter sofrido algum tipo de agressão, o que foi confirmado pelo laudo médico de fls. 60, tudo a demonstrar que sua versão dada em Juízo é absolutamente mendaz.

Tais condutas, portanto, apontam que os Luan e Victor, ao contrário do sustentando, iriam utilizar o entorpecente apreendido para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que devidamente evidenciada a prática do narcotráfico por ambos.

Destarte, a forma como a droga estava acondicionada, o tipo e a grande quantidade

da substância, o local e horário da abordagem, a evasiva e a maneira como ela aconteceu, o fato de ambos serem conhecidos pelo tráfico e não estavam sob efeito de drogas, acoplados às demais circunstâncias do caso em exame evidenciam a finalidade do tráfico ilegal.

Desse modo, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória. Oportuno salientar que “Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, motivo porque não podem ser descartados, notadamente porque os Réus não ofertaram qualquer resistência ao depoimento deles, sendo que alegação de perseguição é genérica e mais vinculada à atuação de ofício dos policiais e, em especial, fosse verdadeira a alegação teriam os Acusados feito prova do alegado.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legalidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, “Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram” (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Destarte, não restam dúvidas que no dia, horário e local indicados na inicial, os Acusados praticaram os fatos ali descritos.

De igual modo, também procede a denúncia em relação à figura tipificada no artigo 35 da Lei de Drogas. A associação para o tráfico é incontestada, pelos motivos acima mencionados, dando conta que tanto Luan quanto Victor se valiam do estabelecimento comercial para disseminação do tráfico.

No caso em tela, desse modo, se vislumbra a reunião estável e permanente, almejando a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Oportuno consignar que, idêntico ao tráfico de entorpecentes, a associação para o tráfico também possui natureza jurídica de crime equiparado ao hediondo e, por isso, deve ter a mesma sistemática.

Também não se pode afastar a prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/03, pois comprovado que o Corréu Victor possuía munição de uso permitido, no interior de seu local de trabalho e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incidindo, assim, no fato tipificado no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Cabe destacar que o laudo de exame do objeto material demonstrou que a munição era apta ao uso a que se destinava (cf. fls. 274/275).

A alegação de que a munição era de seu genitor deveria ser pelo Corrêu Victor comprovada, porque ele sequer estava no estabelecimento, ônus, portanto, que caberia à Defesa, havendo um verdadeiro deserto probatório quanto a tal assertiva.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos Réus ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicar a pena.

Corrêu LUAN: em relação ao crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas, tem-se inicialmente que o Acusado ostenta maus antecedentes, que, contudo, não são empregados nesta fase para não se incorrer em bis in idem com a reincidência. Contudo, é o caso de majorar sua pena-base, considerando a grande quantidade de entorpecente apreendido para os padrões desta cidade, abundância esta que evidencia o claro indicativo de que o comércio clandestino seria abastecido por razoável período e adverte que o Réu possuía posição de destaque na traficância, razão pela qual, atendendo aos critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, com o que promovo o aumento da pena-base em $\frac{1}{2}$ (metade) e a fixo inicialmente em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no menor patamar, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase aumento sua pena em $\frac{1}{3}$ (um terço) em razão da reincidência específica (cf. fls. 72, autos nº 1500936-15.2020.8.26.0530), atingindo o patamar de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa.

Em relação ao delito de associação para o tráfico, estabeleço a pena em seu piso legal, isto é, 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, malgrado seus maus antecedentes, mas visando se evitar bis in idem com a reincidência.

Na segunda fase da dosimetria, considerando sua reincidência, majoro aquela pena em $\frac{1}{3}$ (um terço), chegando à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, no menor valor.

Promovo a soma das penas aplicadas, pois houve a existência de dois resultados pelas duas condutas distintas praticadas, com fulcro no artigo 69 do Código Penal, atingindo o montante de 14 (quatorze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.933 (um mil novecentos e trinta e três) dias-multa, ao valor unitário de $\frac{1}{30}$ (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, estipulada no mínimo legal, sendo que o regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado, por expressa disposição do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90. No mais, é vedada a substituição por pena restritiva de direitos (artigo 33, parágrafo 4º, Lei 11.343/06).

Corrêu VICTOR: Para o crime de tráfico de entorpecentes, em respeito ao estabelecido nos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, ressalto que o Acusado também é possuidor de maus antecedentes, que, contudo, não são empregados nesta fase para não se incorrer em bis in idem com a reincidência. Contudo, é o caso de majorar sua pena-base, considerando a grande quantidade de entorpecente apreendido para os padrões desta cidade, abundância esta que evidencia o claro indicativo de que o comércio clandestino seria abastecido por razoável período e adverte que o Réu possuía posição de destaque na traficância, razão pela qual, atendendo aos critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, com o que promovo o aumento da pena-base em $\frac{1}{2}$ (metade) e a fixo inicialmente em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no menor patamar, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase aumento sua pena em $\frac{1}{3}$ (um terço) em razão da reincidência

específica (cf. fls. 61, autos nº 1500129-45.2019.8.26.0557), atingindo o patamar de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa.

Para o crime de associação para o tráfico estabeleço a pena em seu piso legal, isto é, 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, malgrado seus maus antecedentes, mas visando se evitar bis in idem com a reincidência.

Na segunda fase da dosimetria, considerando sua reincidência, majoro aquela pena em 1/3 (um terço), chegando à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, no menor valor.

Já em relação ao crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/06, para não incorrer em bis in idem com a reincidência e ponderando que fora encontrada pequena quantidade de munição, fixo a pena-base no piso legal, ou seja, em 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no menor valor.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o Réu é reincidente, circunstância agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal com o que majoro sua pena em 1/3 (um terço), dada a persistência na prática de condutas criminosas e de ter sido a munição empregada no contexto de um tráfico com associação de pessoas, estabelecendo-a, portanto, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em seu menor valor, à míngua de comprovação das condições financeiras do Acusado.

Por fim, tendo em vista que o Réu praticou três crimes todos com resultados diversos, aplica-se a regra do artigo 69, caput, do Código Penal, motivo porque promovo a somatória de suas penas, estipulando-a definitivamente em reclusão de 14 (quatorze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.946 (um mil novecentos e quarenta e seis) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, estipulada no mínimo legal, além de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em observância ao aludido artigo 69, caput, do Código Penal, parte final ("No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela").

Os Acusados, reincidentes, não fazem jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos, com considerável quantidade e diversidade de drogas, vem a demonstrar que se dedicam, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas, ainda que, concomitantemente, possuam ocupação lícita.

Nesse diapasão: "Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'. Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder. Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução" (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

Importante consignar que caberia à defesa a prova de que os Acusados fariam jus à causa de diminuição acima mencionada, considerando-se que esta não é automática e somente de aplicação possível quando presentes os requisitos legais, forte no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, ou seja, "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

O regime de cumprimento de pena adequado para ambos os Réus, em relação ao tráfico, por se tratar de crime equiparado ao hediondo - e não há discussão a este respeito em relação ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas, conforme expressa previsão do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal -, é o fechado. Nesse panorama: "O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap. 0000555-39.2016.8.26.0557, 15ª C.D.Crim., Rel. Des. Poças Leitão, j. 01.02.2018).

Ressalto, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido

pelo traficante (ainda que seja um "pequeno" traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada à crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: "Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012).

E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou a substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos objetivo (reincidentes) e subjetivo. Ressalto, quanto a este requisito subjetivo que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que os Acusados possuem condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Anoto, ainda, em relação ao Corrêu Victor, que reincidente e diante da escalada de crimes praticados naquele momento, o regime inicial para cumprimento da pena do crime do artigo 12 da Lei 10.826/03 é o semiaberto, vedadas a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis.

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos, o que não impede a busca de reparação no Juízo Cível.

À derradeira, tendo em vista que os Acusados foram condenados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com eles localizados dinheiro e celular sem comprovação de origem e associados ao tráfico, declaro o perdimento em favor da União desses bens apreendidos, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isso posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, por consequência:

a) CONDENO o Acusado LUAN BATISTA ALVARENGA, com qualificação nos autos, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.933 (um mil novecentos e trinta e três) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, em regime inicial fechado e vedadas a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis, como incurso nas sanções do artigo 33, caput c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal; e

b) CONDENO o Acusado VICTOR GONÇALVES DE LIMA, também qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.946 (um mil novecentos e quarenta e seis) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, vedadas a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis, como incurso nas sanções do artigo 33, caput c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 e do artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

No mais, decreto a perda do dinheiro apreendido com os Corrêus Luan e Victor, bem como telefone celular apreendido com o primeiro, que deverá ser revertido, com o trânsito em julgado, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se os nomes dos Réus no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez do crime, os Réus, descontentes com a decisão, deverão aguardar o julgamento do recurso presos, motivo por que mantenho suas prisões cautelares, sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do CPP, uma vez

que está evidenciado que em liberdade atentaram contra a ordem pública, podendo voltar à prática deste pernicioso crime, nada justificando que presos em flagrante e condenados pela prática inclusive de crime hediondo, reincidentes, fossem postos em liberdade para que aguardassem assim o julgamento de seu recurso, ficando, desta forma, indeferido o pedido defensivo neste sentido.

São devidas as custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA